Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Nova Alvorada do Sul
Vara Única

Autos **0800297-69.2018.8.12.0054**
Autor(es): Leticia Ferreira Nogueira
Réu(s) Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Nova Alvorada do Sul - MS

Leticia Ferreira Nogueira ajuizou a presente ação com pedido de condenação dos requeridos **Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Nova Alvorada do Sul - MS** para que providenciassem insumos necessários pra seu tratamento de diabetes tipo 1, como bomba de insulina minimed, aplicador do conunto de infusão de quick-set, cateter paradigm quick-set, cânula 60cm tubo, reservoir paradigm, transmissor guardian link2, carelink usb e enlite sensores.

A tutela de urgência foi indeferida.

As parte requeridas apresentaram contestação, pugnando pela improcedência do pedido, considerando que há tratamento disponível no SUS, o que impossibilita a escolha da parte requerente, acompanhando o parecer desfavorável do NAT.

Por sua vez, a parte requerente apresentou impugnação a contestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Decido.

Conheço diretamente do pedido, nos moldes do artigo 355, I do CPC, uma vez que a questão de mérito é de direito e de fato, mas não há necessidade de produzir prova em audiência, revelando-se suficiente para a exata compreensão e desate da lide, as provas documentais e pericial produzidas nos autos.

Não há preliminares ou eventuais nulidades a serem analisados

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JESSE CRUCIOL JUNIOR, liberado nos autos em 01/02/2019 às 09:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800297-69.2018.8.12.0054 e código AKMMQm5X.

analisadas.

Como venho ressaltando, a determinação para que o Estado (Poder Público) custeie tratamento particular com verba pública, a favor de um indivíduo e em detrimento dos demais integrantes da sociedade (sem que reste caracterizada omissão estatal) é de escancarada inconstitucionalidade.

É certo que "o direito social à saúde(…) não é absoluto, estando o seu conteúdo vinculado ao bem de todos os membros da comunidade e não apenas ao indivíduo isoladamente (AI nº 70035220508 – 22ª Câmara Cível do TJRS)".

Este caso encerra, talvez, uma hipótese de conflito de direitos constitucionais e sua solução merece atenção à Constituição como um todo, e não à apenas um ou dois dispositivos da Carta. Ademais, mesmo que se enxergue um conflito de direitos constitucionais, a forma de resolução deste conflito deve ser metodologicamente fundamentada, não sendo suficiente referência genérica à preferência do direito à saúde ou à vida. Outrossim, tampouco se deve ater a utilização acrítica de teorias estrangeiras feitas com base no sistema constitucional alienígena (*v.g.* técnica da ponderação, teorias do discurso e dos pesos de Robert Alexy, que tiveram base na jurisprudência pós-guerra do TCF alemão).

Não se pode esquecer que a fruição de direitos fundamentais pela coletividade (bens coletivos) deve ser feita de forma organizada, demandando regulamentação estatal, o que, inclusive, "*exige escolhas trágicas pela impossibilidade de atendimento integral a todos, ao mesmo tempo, no mais elevado standard permitido pela ciência e tecnologia médicas* (AI nº 70035220508)".

Todos sabemos, no âmbito da teoria geral dos direitos fundamentais, que não há hierarquia entre direitos fundamentais. Assim, o direito de cada um (social) à saúde deve ser tomado juntamente com o direito constitucional à igualdade (o direito é de todos, e não de um ou alguns). Além do mais, há as inafastáveis regras de controle e aplicação do dinheiro público (público: de todos), previstas entre outros nos arts. 163 e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JESSE CRUCIOL JUNIOR, liberado nos autos em 01/02/2019 às 09:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800297-69.2018.8.12.0054 e código AKMMQm5X.

seguintes da Constituição.

Veja que o art. 196 da Constituição não vale mais que o seu art. 163, o 165, ou outro qualquer. Todos são dispositivos constitucionais válidos e eficazes. Não se pode ignorar ainda que é direito fundamental dos cidadãos o bem versar sobre o dinheiro público e o desenvolvimento de políticas públicas efetivas, dentro das possibilidades fáticas.

Ainda, não se deve olvidar que são garantias institucionais (fundamentais, portanto) dos cidadãos a separação dos poderes e a garantia de concretização da Constituição por meio da criação e implementação de políticas públicas através dos órgãos legitimamente eleitos pelo povo para tanto.

O Poder Judiciário não cria, modifica ou implementa política pública, pois os arts. 93 e seguintes da Constituição não lhe conferem essa missão, nem mesmo implicitamente. Caso contrário haveria malferimento do princípio fundamental da separação dos poderes e uma indevida ingerência de um Poder nos demais.

Não pode assim, haver a invocação pura e simples do art. 196 da Constituição para embasar a concessão de medida em face do Estado para que custeie com direito público tratamento específico sem que haja pressupostos constitucionais para isso, limitando à urgência do caso.

Não se observando essas peculiaridades, além do desrespeito aos famigerados princípios orçamentários (válidos, eficazes e impositivos por força constitucional) pesa aí possível e provável ofensa ao direito fundamental de igualdade, pois o dinheiro destinado à saúde em geral (atendimentos na área) seria desviado por ordem judicial para atender a um cidadão específico. Ora, e os demais? que aguardam em fila? Como pode o Poder Judiciário ser compelido a escolher entre o atendimento de tal ou qual demanda de saúde (escolhas trágicas citadas no *AI 70035220508* do TJRS)?

É fato notório que diariamente pessoas morrem ou passam mal nas filas de postos de saúde e hospitais por falta de atendimento ou medicação, e isso é um fato

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JESSE CRUCIOL JUNIOR, liberado nos autos em 01/02/2019 às 09:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800297-69.2018.8.12.0054 e código AKMMQm5X.

lamentável. Mas independente disso, mesmo com o ajuizamento de ações como a presente outras continuarão a morrer e a passal mal no sistema público de saúde (escolhas trágicas), pois o foco foi desviado de um (que ajuizou ação) para outro (que não ajuizou).

Logo, do ponto de vista constitucional haverá um tratamento desigual (um recebeu atendimento e outro não) cujo fator de descrímem será o ajuizamento da ação judicial.

Pode o Poder Judiciário escolher quem será ou não atendido com base no critério do ajuizamento da ação?

A limitação nos atendimento é um fato social/econômico/político e não será resolvido com o ajuizamento de ações individuais.

Veja que o Judiciário estará administrando (fazendo escolhas de demandas públicas), sem mesmo ter subsídios técnicos para organizar a fruição simultânea de bens públicos pela coletividade.

E se a ação fosse coletiva? O resultado seria diferente? Poderia o Judiciário determinar que todos recebam atendimento no âmbito daquela ação? Qual seria o alcance? E os resultados?

São questões complexas que não podem ser resolvidas sem um profundo debate constitucional, principalmente com a utilização isolada do art. 196 da CF.

Isso não significa, por outro lado, que o Judiciário não possa agir quando haja desrespeito à Constituição. Demonstrada *omissão estatal* no atendimento de demandas públicas (inclusive de saúde), dentro das possibilidades fáticas, provocado, o Poder Judiciário tem o poder de impor a volta da chamada legalidade constitucional, ou seja, o respeito às normas constitucionais, aí sim determinando legitimamente a implementação de políticas públicas.

Entretanto, no presente caso não há sério indício de omissão estatal, pois há tratamento disponível na rede pública inclusive amplamente difundido em todos os

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JESSE CRUCIOL JUNIOR, liberado nos autos em 01/02/2019 às 09:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800297-69.2018.8.12.0054 e código AKMMQm5X.

municípios, como é de conhecimento geral, com insumos suficientes para controle da enfermidade, o que pode se concluir também pelo relatório encaminhado pelo NAT (fls. 37/43), não havendo razão para ser "beneficiada" em detrimento dos demais pacientes que aguardam os mesmos exames e estão inseridos no mesmo sistema.

Vale dizer que a infusão contínua de insulina pleiteada não é padronizada pela rede pública, contudo, conforme se observa, há outras medidas tão efetivas quanto, conforme parecer do NAT, capazes de controle da doença, não havendo necessidade de tratamento diferenciado.

Além disso, não há nos autos qualquer documento médico que demonstre que os medicamentos disopnibilizados pela rede pública são ineficazes para o tratamento da requerente.

Como consta da Lei 8.080/90 (art. 19-M) assistência terapêutica integral, consiste em **"II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado".**

Havendo tratamento eficaz fornecido pelo SUS, não há que se falar em negativa injustificada.

Atender a todas as solicitações individuais, sem qualquer planejamento, ocasionaria um gasto muito maior, podendo acarretar [grande] desperdício de recursos públicos, o que contraria os princípios orçamentários previsto na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal e geraria o atendimento de menos pessoas (menos recursos disponíveis significa menos atendimentos), prejudicando, ao fim e ao cabo, o atendimento das demandas de saúde da população como um todo.

Logo, não há qualquer razão para se determinar que o estado custeie isoladamente o tratamento de saúde de um cidadão, o que teria a incrível potencialidade de desviar coercitivamente recursos na área de saúde que poderia beneficiar vários

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JESSE CRUCIOL JUNIOR, liberado nos autos em 01/02/2019 às 09:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800297-69.2018.8.12.0054 e código AKMMQm5X.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Nova Alvorada do Sul
Vara Única

outros cidadãos. A proteção individual não pode se sobrepor à proteção coletiva, dentro de um certo contexto e das possibilidades fáticas existentes.

Assim, havendo tratamento disponível na rede pública de saúde (afastando omissão estatal) não é possível conceder a tutela para a satisfação de pretensão individual.

Por fim, a par da ausência de fundamento para determinação do custeio do tratamento solicitado, a alegação de que são necessárias mais doses da injeção prescrita é feita com base exclusivamente em médico da rede privada, não havendo impugnação ao protocolo clínico do SUS para o tratamento em questão (que já está sendo realizado).

Desse modo, o pedido deve ser julgado improcedente.

Posto isso, julgo extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para o fim de rejeitar a pretensão inicial.

Condeno a requerente, ainda, ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa sua cobrança conforme o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.Transitada em julgado, arquive-se.

P.R.I

Nova Alvorada do Sul, 01 de fevereiro de 2019.

(assina por certificação digital)
Jessé Cruciol Junior
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JESSE CRUCIOL JUNIOR, liberado nos autos em 01/02/2019 às 09:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800297-69.2018.8.12.0054 e código AKMMQm5X.